

1501409-49.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... já possui histórico de envolvimento com tráfico, conforme certidão de antecedentes

Por fim, o simples fato de eventualmente ser usuário não afasta a configuração do tráfico, já que esses elementos não são excludentes.

Logo, está bem caracterizado o tráfico de drogas.

A prova é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep 07401-125

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501409-49.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501409-49.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142413/2021 - DEL.POL.ARUJA, 18131619 - DEL.POL.ARUJA, 920/21/201 - DEL.POL.ARUJA, 2142413 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI SANTOS FERREIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

DAVI SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, "Consta dos autos do incluso inquérito policial que, na data de 25 de maio de 2021, às 19h17min, na Rua das Perdizes, nº 155, Mirante, Arujá/SP, DAVI SANTOS FERREIRA, com consciência e vontade, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, item 1) 44 (quarenta e quatro) porções de crack, com peso de 29,1 gramas e item 2) 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso de 21,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo de constatação de fls. 10/14 e auto de exibição e apreensão de fls. 15/16)" (fls. 54).

O flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 40/42). Foi notificado (fls. 97) e apresentou defesa prévia (fls. 104/106). Recebida a denúncia (fls. 111), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu o acolhimento dos pedidos, nos termos da denúncia. Em síntese, a defesa requereu a absolvição, sustentando que as provas são precárias.

B) ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Imputa-se a prática do seguinte crime da Lei 11.343/06:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas".

A pretensão punitiva é procedente.

O fato existiu. A materialidade está comprovada pela prova oral produzida; boletim de ocorrência (fls.06/08); auto de exibição e apreensão (fls.15/16); laudo de constatação provisório (fls.83/85) e laudo pericial definitivo (fls.89/90), que atestam que a substância encontrada era de uso proibido pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998: item 1 - 44 (quarenta e quatro) porções de crack, com peso de 29,1 gramas de massa bruta e item 2 - 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso de 21,6 gramas de massa líquida.

Também não há dúvida da autoria.

A testemunha Felipe da Silva Pereira disse em sede policial que "Que é policial militar e estava em patrulhamento ostensivo e preventivo juntamente com seu colega de farda JONAS e informa que em patrulhamento pela via quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita e que ao visualizar a viatura demonstrou nervosismo e começou a fingir que falava com sua mãe pelo telefone celular. Diante disso os ostensivos iniciaram a abordagem, e após a inspeção minuciosa foi localizado com o indiciado entorpecentes e dinheiro trocado, o mesmo ainda tentou empreender fuga porém foi contido, razão pela qual os ostensivos conduziram o indiciado até PAM BARRETO e posterior a esta Delegacia. Asseveraram ainda os ostensivos que após o procedimentos algemaram o indiciado DAVI, e constaram que haviam 44 microtubos de substância aparentemente de crack e 45 microtubos de substância aparentemente de cocaína e a importância em dinheiro de R\$ 61,00 reais, e apresentaram a ocorrência a Autoridade Policial de plantão".

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que foi dar apoio a uma viatura, que não avistou o réu. O depoente avistou o réu na rua falando ao celular, com sua genitora. Localizou uma bolsa e tentou empreender fuga. Não se recorda quem fez a busca pessoal. A droga foi encontrada em uma bolsinha. Foi algemado pois resistiu. A testemunha Jonas Queiroz do Nascimento disse em sede policial que "Que é policial militar e estava em patrulhamento ostensivo e preventivo juntamente com seu colega de farda FELIPE e informa que em patrulhamento pela via quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita e que ao visualizar a viatura demonstrou nervosismo e começou a fingir que falava com sua mãe pelo telefone celular. Diante disso os ostensivos iniciaram a abordagem, e após a inspeção minuciosa foi localizado com o indiciado entorpecentes e dinheiro trocado, o mesmo ainda tentou empreender fuga porém foi contido, razão pela qual os ostensivos conduziram o indiciado até PAM

BARRETO e posterior a esta Delegacia. Asseveram ainda os ostensivos que após o procedimentos algemaram o indiciado DAVI, e constaram que haviam 44 microtubos de substância aparentemente de crack e 45 microtubos de substância aparentemente de cocaína e a importância em dinheiro de R\$ 61,00 reais, e apresentaram a ocorrência a Autoridade Policial de plantão. "

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que estava em patrulhamento pela via e avistou o Davi em atitude suspeita, pegando o celular e conversando com alguém. Com o depoente foram encontradas drogas e dinheiro. As drogas estavam em uma bolsa, ele estava segurando. Eram microtubos, cocaína e crack. Ele estava parado na rua, não tinha ninguém. Ao fazer algemamento, ele tentou empreender fuga mas foi contido. Foi solicitado apoio de outras viaturas, mas quando chegaram ele já estava contido. Ficou em silêncio no momento. Não conhecia o réu.

O réu Davi Santos Ferreira permaneceu em silêncio na fase policial. Em Juízo, disse que realmente estava traficando, mas as drogas não estavam com o depoente. Quando viu a viatura fingiu que estava falando com o telefone. A droga realmente estava na bolsa, mas ela estava embaixo de um bloco. Estava vendendo droga desde as 6h, o dia inteiro. Estava com lucro de R\$1400,00.

Embora a inocência deva ser presumida, ao final da instrução a acusação cumpriu seu ônus de demonstrar os fatos alegados na denúncia.

Com efeito, os policiais narraram em Juízo que abordaram o réu em atitude suspeita na rua e na abordagem encontraram droga (muitas porções de crack e cocaína) em uma bolsa.

Não há nada nos autos que evidencie que o agente de segurança tenha motivo para incriminar o réu de forma proposital. Por isso, deve prevalecer a versão do agente público, que age presumidamente na forma a lei, e cujo relato é coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas existentes no processo. A jurisprudência é farta nesse sentido.

Por outro lado, o réu não trouxe qualquer elemento que contrariasse tais premissas, sendo certo que o ônus da "prova da alegação incumbirá a quem a fizer" (art. 156, CPP). Ao contrário, admitiu a prática do delito, confissão que está em conformidade com os demais elementos dos autos.

Ademais, o tráfico de drogas não se consuma apenas com o ato típico de "venda". Se o acusado pratica qualquer uma das 18 condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06 terá incorrido no crime, inclusive na hipótese de apenas "ter em depósito", "guardar" ou "trazer consigo" a droga.

Mesmo a conduta de "oferecer" não exige a finalidade lucrativa, pois a lei tipifica as condutas praticadas "ainda que gratuitamente". Na realidade, o intuito de lucro é apenas uma circunstância negativa que justifica aumento da pena. Por isso, não se exige um elemento subjetivo especial, ou seja, a demonstração da intenção específica de praticar atos de mercancia. Basta o dolo genérico, a consciência e vontade de realizar alguma das ações que configuram o crime e dispensam intenção de venda.

O elemento subjetivo é determinante apenas para se descartar a hipótese de porte ou guarda da droga para uso pessoal, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Segundo o §2º deste dispositivo, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Sobre o tema, é relevante observar que o tráfico muitas vezes é praticado por indivíduos com pequenas porções, justamente para tentar ludibriar a repressão estatal. Por isso, a análise da quantidade é sempre relativa, a partir da realidade local e demais circunstâncias, sob pena de se admitir a livre circulação de entorpecentes sem que exista tráfico, o que é logicamente impossível.

Feita essa ressalva, no caso concreto a quantidade não era compatível com a figura de mero usuário, ao menos para a realidade local (quase 90 porções de crack/cocaína). O próprio réu admitiu que estava vendendo droga no local desde às 6h da manhã, aferindo lucro de R\$1.400,00. E já possui histórico de envolvimento com tráfico, conforme certidão de antecedentes

Por fim, o simples fato de eventualmente ser usuário não afasta a configuração do tráfico, já que esses elementos não são excludentes.

Logo, está bem caracterizado o tráfico de drogas.

A prova é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal e material. Sua conduta foi contrária ao direito, era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

C) DOSIMETRIA

O Juiz deve concretizar a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) analisando as particularidades da infração e condições pessoais do réu, buscando uma pena "suficiente para reprovação e prevenção" (art. 59, CP).

O objetivo é fixar uma pena justa para a situação concreta, diferenciando-a das inúmeras outras em que o mesmo crime poderia ser cometido, por diversas pessoas e seus motivos, diferentes formas de execução, consequências individuais e coletivas. Na primeira etapa, as frações de aumento devem incidir preferencialmente sobre o intervalo abstrato entre a pena mínima e a máxima. Esse critério é mais adequado especialmente em crimes nos quais a distância entre as penas mínimas e máximas é expressiva, tal como no tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. Se aplicada a fração de aumento sobre a pena mínima, a reprimenda nunca iria superar 10 anos de reclusão na primeira fase, mesmo em casos graves (aumento de 8/8). Isso deixaria de considerar toda a margem de variação prevista pelo legislador e tornaria a pena injusta.

Assim, "embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos" (grifei).

Nos crimes da Lei 11.343/06 merecem destaque ainda "a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (art. 42). O réu ostenta mau antecedente (autos nº 1503130-07.2019.8.26.0535) pela prática do mesmo crime.

A natureza e a quantidade de drogas autorizam o aumento da pena base, dado seu maior potencial destrutivo e viciante, acarretando igualmente maiores transtornos sociais e esforços do Poder Público em combatê-los.

O crime se consuma por condutas realizadas "ainda que gratuitamente" (art. 33, "caput"). Por isso, aquele que visa a praticar atos de comércio ou promessa de recompensa financeira realiza conduta mais grave entre as várias previstas pelo legislador como elementares. Como bem jurídico foi lesionado de forma mais acentuada, a pena deve ser maior. É a situação do réu, que praticava a conduta com o objetivo de aferir lucro, e inclusive admitiu que apenas naquele dia faturou R\$1.400,00.

As consequências do tráfico na Comarca e região são particularmente graves. Não se trata de análise da gravidade em abstrato do delito, mas sim da constatação empírica dos efeitos na comunidade local, a partir da experiência concreta deste Magistrado com situações reais.

Violência doméstica, furtos, roubos, ameaças, etc., quase sempre são praticados quando o infrator está sob os efeitos da droga ou buscando arrecadar dinheiro para adquiri-la. São múltiplos na região os casos de crianças e adolescentes que têm suas vidas destruídas pelas drogas, quer pelo consumo, quer pela atividade de traficância - que normalmente envolve outros ilícitos e evasão escolar -, ou ainda pela absoluta falta de estrutura familiar de mães e pais usuários. É grande a deturpação na vida do indivíduo que está em fase de desenvolvimento e formação de caráter.

Portanto, independentemente da quantidade, a lesividade concreta é elevada pois a conduta não pode ser analisada apenas na perspectiva individual, mas também coletiva.

Diante dessas circunstâncias negativas, majoro a pena base em 3/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima (ou seja, 10 anos), fixando-a em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Verifico a atenuante da confissão e da menoridade relativa, o que enseja redução da pena em apenas 1/5, atingindo 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando os antecedentes, com condenação recente pelo mesmo crime, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06). Por isso, a reprimenda final é a mencionada acima.

Fixo o regime inicial fechado. A prática anterior de tráfico de drogas e as circunstâncias desfavoráveis apontadas (natureza; significativa quantidade para a realidade da Comarca; ação que visava o lucro; efeitos sociais específicos do tráfico na Comarca) demonstram maior lesividade concreta do delito e exigem um agravamento do regime inicial para que a pena seja suficiente para a reprovação e prevenção (art. 33, §3º, CP).

Independentemente da quantidade da pena, tais circunstâncias subjetivas desfavoráveis também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, CP) ou a concessão do benefício da suspensão condicional (art. 77, II, CP).

Eventual detração penal (art. 387, §2º, CPP), se for o caso, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, único com competência para verificar a presença ou não dos requisitos subjetivos.

D) CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu DAVI SANTOS FERREIRA como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, na pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, regime inicial fechado, dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo.

Mantenho a prisão preventiva.

Os antecedentes e processos criminais do sentenciado justificam a manutenção da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública, já que a confiança anteriormente depositada pelo Estado não foi suficiente para que as normas de convívio social fossem respeitadas. As circunstâncias judiciais desfavoráveis acima apontadas demonstram expressiva lesividade concreta da conduta, a justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ademais, não existem alterações de fato ou de direito que infirmem os argumentos da decisão que decretou a segregação cautelar, que ora ficam reiterados. Na realidade, a prisão para a garantia da ordem pública se torna ainda mais necessária depois do amplo contraditório e confirmação da culpa em sentença proferida com cognição exauriente. Com a condenação, eventual direito a progressão de regime poderá ser analisado pelo Juízo da Execução.

Expeça-se guia de execução, recomendando-se no estabelecimento penal em que se encontra.

Declaro o perdimento dos bens apreendidos em favor da União (dinheiro) (art. 63, I e §1º, Lei 11.343/06). Autorizo a devolução do celular.

Fica o réu condenado ao pagamento das custas (art. 804, CPP), observada eventual gratuidade concedida nos autos.

Expeça-se certidão de honorários, se for o caso, ficando a remuneração arbitrada em grau máximo.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões e, oportunamente, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para destruição de eventual contraprova (art. 72, Lei 11.343/06) e comunique-se ao IIRGD e ao TRE.

Publique-se. Saem as partes intimadas em audiência. Cumpra-se.
Aruja, 31 de março de 2022.